Tribunal de Justiça de Minas Gerais

Número do	1.0223.05.170615-6/001	**Númeração**	1706156-
Relator:	Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho		
Relator do Acordão:	Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho		
Data do Julgamento:	08/08/2023		
Data da Publicação:	11/08/2023		

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DA ASSISTÊNCIA DA ACUSAÇÃO - PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO PELO CRIME DO ART. 288, CP - ILEGITIMIDADE - NÃO CONHECIMENTO - ESTELIONATO - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO - RECURSOS DEFENSIVOS PREJUDICADOS - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - NULIDADE - VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA - REVISÃO DO CONTEÚDO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - REDUÇÃO DA PENA-BASE - ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL - RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Há que se reconhecer a ilegitimidade do assistente (vítima de roubo) para apresentar o ponto de inconformismo relativo à absolvição dos acusados da prática do delito previsto no art. 288, caput, do Código Penal, cujo sujeito passivo é a coletividade. A assistência da acusação é ocupada pelo ofendido ou alguém relacionado a ele, postulando e atuando secundariamente (não como acusador principal). Por ofendido entenda-se, tecnicamente, o sujeito passivo da infração. Para o delito do art. 288, caput, identificado o sujeito passivo como sendo a coletividade, conclui-se pela inviabilidade da atuação do assistente, vítima de outro crime. Sabe-se que a previsão acerca da possibilidade de admissão da assistência da acusação não altera a exclusividade estatal do ius puniendi. Nas alegações finais do Ministério Público, não há pedido de condenação pelo crime do art. 288, CP. Para além do que já foi dito acima, diante da delimitação da pretensão acusatória após a realização da instrução criminal, não há legitimidade da assistência para pleitear uma condenação não pedida pelo Ministério Público. É evidente que a atuação da assistência, quando admitida, é assessória, sendo que o processo penal dele não depende para se

instaurar e se desenvolver. Cumprida a instrução criminal, o Ministério Público não pleiteou a condenação pelo crime do art. 288, CP. Não poderia a assistência (que para este delito nem é admitida) atuar como se acusador "supra" fosse, contrariando a titularidade ministerial. Por todos os ângulos, constata-se a ilegitimidade que impõe o não conhecimento do primeiro recurso.

Considerando a pena individualmente aplicada, para cada delito, não superior a dois anos, há que se observar o lapso prescricional de quatro anos. Entre a data do recebimento da denúncia - 21/03/2007 - e a data da publicação da sentença condenatória - 01/02/2018 - decorreu período superior a quatro anos. Tais penas transitaram em julgado para a acusação. Deve ser decretada a extinção da punibilidade relativa ao crime de estelionato para os apelantes pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.

Em atenção à atuação colegiada e à luz do que majoritariamente está estampado nos precedentes do STJ, rejeita-se a preliminar da defesa sobre vício de motivação. O STJ firmou a tese de que "A utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir" (Tese 18 da Ed. n º 69). Destaca-se que a tese é aplicada levando em conta as circunstâncias e a natureza das decisões, pois, ao mesmo tempo em que admite a remissão, por exemplo, nas decisões em procedimentos de interceptação telefônica, o tribunal é mais cauteloso sobre este procedimento quando se analisa o mérito em sentenças e acórdãos. Para o caso em apreço, conclui-se que a metodologia utilizada pelo juízo a quo está em consonância com precedentes do STJ.

Ao contrário do que alega a defesa, a palavra da vítima não sustenta isoladamente a condenação prolatada e não está em dissonância com as demais provas produzidas. Havendo respaldo e claro apontamento na sentença dos elementos de prova suficientes, deve ser mantida a condenação.

A reprimenda foi aplicada a partir de concreta motivação quanto à

culpabilidade. Há, contudo, reparo a ser feito quanto às análises desfavoráveis da personalidade, dos motivos e das consequências do crime. Os conteúdos apresentados estão inseridos nos contornos da própria prática criminosa, da persecução criminal e do tipo penal em apreço, desafiando revisão.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1.0223.05.170615-6/001 - COMARCA DE DIVINÓPOLIS - 1º APELANTE: ASSISTENTE MINISTÉRIO PÚBLICO - 2º APELANTE: WALTER DIAS DE ALMEIDA - 3º APELANTE: CARLOS ALBERTO PEREIRA DA SILVA - 4º APELANTE: FELÍCIO ABRAS FILHO - 5º APELANTE: EDMAR DA SILVA - APELADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

A C Ó R D Ã O

Vistos etc., acorda, em Turma, a 5ª CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos, em NÃO CONHECER DO PRIMEIRO RECURSO, DAR POR PREJUDICADOS OS TERCEIRO, QUARTO E QUINTO RECURSOS E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO SEGUNDO RECURSO, APÓS REJEITAR SUAS PRELIMINARES.

DES. ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO

RELATOR

DES. ALEXANDRE VICTOR DE CARVALHO (RELATOR)

V O T O

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto pelo assistente do Ministério Público (1º apelante) e pelos acusados Walter Dias de Almeida (2º apelante), Carlos Alberto Pereira dos Santos (3º apelante), Felício Abras Filho (4º apelante) e Edmar da Silva (5º apelante) contra sentença oriunda do juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Divinópolis que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar WALTER DIAS DE ALMEIDA como incurso nas sanções dos art. 157, §2º, incisos I e II e art. 171, caput, ambos do Código Penal; CARLOS ALBERTO PEREIRA DOS SANTOS nas sanções do art. 171, caput, do Código Penal; CELSO VICTÓRIA DE MORAIS PEREIRA nas sanções dos art. 299 e art.171, caput, (duas vezes) c/c art. 69, todos do Código Penal; EDMAR DA SILVA nas sanções do art. 171, caput, do Código Penal e FELÍCIO ABRAS FILHO nas sanções do art. 171, caput, (duas vezes) c/c art. 71, ambos do Código Penal.

Fato 1 - Narra a denúncia que na data de 07 de abril de 2005, por volta das 12 horas, na Rua Afrânio Peixoto, nº. 121, bairro Catalão, nesta cidade, os denunciados Carlos Alberto, Celso Victória e Walter Dias, com mais três indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram aproximadamente R$380.000,00 em cheques diversos, R$600,00 em dinheiro, uma pistola semiautomática calibre 380 com 2 carregadores, um revólver calibre 32, dois telefones celulares, aparelho de toca CD da marca Pionner, cartões de crédito, talões de cheques e documentos pessoais pertencentes à vítima Alexandre Daldegan Custódio, além de talões de cheques de Nélson Custódio e Cláudio Duarte Pereira.

Fato 2 - Consta que o acusado Celso Victória se fazia passar pela pessoa de Idelfonso Geraldo dos Santos, falecido em data de 01/05/03, tendo falsificado os documentos deste, o que lhe propiciou a abertura de conta em nome de Idelfonso, onde foram depositados vários dos cheques subtraídos.

Fato 3 - Narra a denúncia que o acusado Celso Victória emitiu

cheques em nome de Idelfonso Geraldo dos Santos, visando obtenção de vantagem ilícita mediante artifício, ou seja, utilizou três cheques para quitar dívida com a empresa Futuraço, e um outro cheque foi utilizado para pagar duas prestações de financiamento de um veículo em nome de sua ex-sogra.

Fato 4 - Consta que o acusado Carlos Alberto se fazia passar por Mauro Custódio da Silva, tendo falsificado os documentos deste, e conseguindo abrir uma conta no banco Bradesco. Consta, ademais, que Carlos Alberto Pereira dos Santos, utiliza também o nome Carlos Alberto Pereira da Silva, possuindo dois números de RG.

Fato 5 - Consta que o quarto acusado, Edmar da Silva tinha débito com a vítima Alexandre no valor aproximado de R$50.000,00, garantido por cheques de sua emissão e, visando resgatar tais cheques, induziu a vítima Alexandre Daldegan a receber cheques falsificados e supostamente emitidos por Mauro Custódio.

Fato 6 - Consta ainda que o quinto denunciado, Felício Abras, adquiriu várias folhas de cheque que sabia serem produtos de crime, pois subtraídos das vítimas Alexandre e Cláudio, e visando a obtenção de vantagem ilícita mediante artifício, passou a emitir e repassar as cártulas, como forma de pagamentos de mercadorias por ele adquiridas.

Fato 7 - Consta que o acusado Felício passou a Romero Miguel Teixeira dois cheques nº. 000465 e 000464, Banco Mercantil, conta 02715170-1, preenchidos nos valores de R$1.200,00 e R$1.150,00, respectivamente, cheques estes que também eram roubados.

Fato 8 - Diz ainda a denúncia que o acusado Walter Dias tinha dívida para com a vítima Alexandre Daldegan em valor aproximado de R$54.000,00, e logo após o assalto, a vítima lhe pediu que guardasse, na casa de um vizinho, duas pastas, sendo uma de cor cinza e outra de cor preta, bem como um HD que continha armazenado a relação de todo o montante do débito, mas Walter se apropriou desta pasta, pois nela havia as anotações de sua dívida para com Alexandre.

Fato 9 - Consta que Walter, após o assalto, entrou em contato com o proprietário da empresa Bross Confecções Ltda., e pediu que fosse enviado novos cheques, o que foi feito pela empresa, tendo emitido um total de nove cheques, entretanto, Walter somente repassou à vítima Alexandre, apenas três cheques, apropriando-se dos restantes seis cheques.

Fato 10 - Por fim, consta da denúncia que o acusado Walter, visando obtenção de vantagem indevida, mediante fraude, entregou à vítima Alexandre vários cheques falsificados.

A sentença impôs as seguintes penas:

- Para Walter Dias, oito anos, dois meses e doze dias de reclusão, regime fechado, e trinta e nove dias-multa;

- Para Carlos Alberto, um ano e oito meses de reclusão, regime aberto, e dezessete dias-multa, tendo sido a pena reclusiva substituída por duas penas restritivas de direitos;

- Para Celso Victória, três anos e cinco meses de reclusão, regime aberto, e trinta e oito dias-multa, tendo sido a pena reclusiva substituída por duas penas restritivas de direitos (falecido);

- Para Edmar da Silva, um ano e oito meses de reclusão, regime aberto, e dezessete dias-multa, tendo sido a pena reclusiva substituída por duas penas restritivas de direitos;

- Para Felício Abras, dois anos, dois meses e vinte dias de reclusão, regime aberto, e vinte e quatro dias-multa, tendo sido a pena reclusiva substituída por duas penas restritivas de direitos.

As razões recursais do assistente da acusação (vítima Alexandre Daldegan Custódio) apresentam o seguinte ponto de inconformismo: os acusados devem ser condenados pela prática do delito previsto no art. 288, caput, do Código Penal.

As razões recursais dos acusados apelantes foram apresentadas, bem como as contrarrazões recursais, após cumprimento de diligências.

Foi colhida a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça na condição de custos legis.

É o relatório.

CONHECIMENTO

O primeiro recurso, da assistência da acusação, não deve ser conhecido. Há que se reconhecer a ilegitimidade do assistente (vítima Alexandre Daldegan Custódio, de outro crime) para apresentar este ponto de inconformismo: os acusados devem ser condenados pela prática do delito previsto no art. 288, caput, do Código Penal (cujo sujeito passivo é a coletividade).

A assistência da acusação é ocupada pelo ofendido ou alguém relacionado a ele, postulando e atuando secundariamente (não como acusador principal). Por ofendido entenda-se, tecnicamente, o sujeito passivo da infração. Para o delito do art. 288, caput, identificado o sujeito passivo como sendo a coletividade, concluiu-se pela inviabilidade da atuação do assistente (vítima de outro crime) Alexandre.

Sabe-se que a previsão acerca da possibilidade de admissão da assistência da acusação não altera a exclusividade estatal do ius puniendi. Neste caso concreto, o Ministério Público apresentou alegações finais nos seguintes termos:

Nas alegações finais o Ministério Público requereu a condenação dos acusados: Walter Dias de Almeida nas sanções do art. 157, §2º, I e II (fato 1); art. 171, caput, (fato 5), art. 168 c/c 69 (duas vezes), (fato 8 e 9), todos do Código Penal; Carlos Alberto Pereira da Silva nas sanções do art. 171, caput, do Código Penal (fato 5); Celso Victoria de Moraes Pereira nas sanções do art. 299 (fato 2) e art. 171, caput, c/c art. 69, (duas vezes) (fato 3), todos do Código Penal; Edmar da Silva nas sanções do art. 171, caput, do Código Penal, (fato 5) e Felício Abras nas sanções do art. 171, caput, (duas vezes) c/c art. 71, ambos do Código Penal (fatos 6 e 7).

Não há pedido de condenação pelo crime do art. 288, CP. Para além do que já foi dito acima, diante da delimitação da pretensão acusatória após a realização da instrução criminal, não há legitimidade da assistência para pleitear uma condenação não pedida pelo Ministério Público.

É evidente que a atuação da assistência, quando admitida, é assessória, sendo que o processo penal dele não depende para se instaurar e se desenvolver.

Cumprida a instrução criminal, o Ministério Público não pleiteou a condenação pelo crime do art. 288, CP. Não poderia a assistência (que para este delito nem é admitida) atuar como se acusador "supra" fosse, contrariando a titularidade ministerial. Por todos os ângulos, constata-se a ilegitimidade que impõe o não conhecimento do primeiro recurso.

Conheço dos segundo, terceiro, quarto e quinto recursos pelo ajuste legal.

PRELIMINAR

EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO

Ocorreu, em relação ao delito de estelionato praticado por Walter, Carlos Alberto, Edmar e Felício, a prescrição da pretensão punitiva, modalidade retroativa.

Considerando a pena individualmente aplicada, para cada delito, não superior a dois anos, há que se observar o lapso prescricional de quatro anos. Entre a data do recebimento da denúncia - 21/03/2007 - e a data da publicação da sentença condenatória - 01/02/2018 - decorreu período superior a quatro anos. Tais penas transitaram em julgado para a acusação.

Decreto a extinção da punibilidade relativa ao crime de estelionato para os apelantes Walter, Carlos Alberto, Edmar e Felício pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva.

Subsiste, assim, apenas a condenação de Walter Dias de Almeida pela prática do delito de roubo majorado para continuidade deste julgamento.

PRELIMINAR DE ILICITUDE DAS PROVAS CAUTELARES

Passo a apreciar a questão preliminar trazida pela defesa do apelante Walter Dias de Almeida em seus memoriais juntados às f. 2095/2118.

Não há que se falar em preclusão consumativa e desconsideração

de tal peça apresentada pelos novos defensores do acusado. De modo bastante objetivo, o processo penal, para muito além de não impedir, impõe a apreciação de qualquer tese favorável ao réu, ainda que sem provocação da defesa. O apelo do acusado devolve à instância revisora toda a matéria - ampla devolutividade. Assim, ainda que não tivesse sido alegada, a questão da (i)licitude das provas cautelares poderia ser conhecida e decidida em favor do acusado.

Sustenta a defesa do apelante que a decisão que determina a busca domiciliar, a interceptação telefônica e o afastamento do sigilo financeiro deve ser fundamentada, com apontamento dos requisitos legais.

No caso concreto, esclarece que, durante as investigações, foram solicitadas as quebras de sigilo bancário e telefônico de todos os acusados, incluindo o apelante, bem como a interceptação telefônica e a busca e apreensão de cheques. Com a concordância do Ministério Público, o pedido foi deferido. Segundo a defesa, a decisão de deferimento, datada de 13 de maio de 2005, não foi minimamente fundamentada.

Em atenção à atuação colegiada e à luz do que majoritariamente está estampado nos precedentes do STJ, rejeito esta preliminar da defesa.

O STJ firmou a tese de que "A utilização da técnica de motivação per relationem não enseja a nulidade do ato decisório, desde que o julgador se reporte a outra decisão ou manifestação dos autos e as adote como razão de decidir" (Tese 18 da Ed. n º 69). Destaca-se que a tese é aplicada levando em conta as circunstâncias e a natureza das decisões, pois, ao mesmo tempo em que admite a remissão, por exemplo, nas decisões em procedimentos de interceptação telefônica, o tribunal é mais cauteloso sobre este procedimento quando se analisa o mérito em sentenças e acórdãos. Para o caso em apreço, conclui-se que a metodologia utilizada pelo juízo a quo está em consonância com precedentes do STJ. São inúmeras as decisões monocráticas e, para ilustrar, cito o recentíssimo julgamento:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. MANDADO QUE ATENDEU AOS REQUISITOS LEGAIS. ILICITUDE DAS PROVAS. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. DECISÃO SUCINTA, PORÉM, FUNDAMENTADA. "PER RELATIONEM". AGRAVO DESPROVIDO.

1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que "não há que se falar em nulidade de mandado de busca e apreensão e, consequentemente, das provas obtidas com a realização da diligência, se evidenciado que todos os requisitos legais para o deferimento da medida e sua execução foram atendidos" (AgRg no AREsp n. 1.226.836/SC, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe de 1º/8/2018).

2. No caso, verifica-se que houve o deferimento pelo Juiz primevo de busca e apreensão na residência do ora agravante, mediante representação da autoridade policial, baseada em investigação e diligências, em razão de movimentações suspeitas no domicílio do acusado observadas por policiais em campana, com presença de carros e diversos indivíduos que contatavam o acusado; sendo apreendidos no local 943,51g (novecentos e quarenta e três gramas e cinquenta e um centigramas) de cocaína, divididos em 246 (duzentos e quarenta e seis) porções, 443,51g (quatrocentos e quarenta e três gramas e cinquenta e um centigramas) de cocaína na forma de crack, divididos em 138 (cento e trinta e oito) porções, e 4.639,49g (quatro quilos seiscentos e trinta e nove gramas e quarenta e nove centigramas) de maconha, o que demonstrou a suposta prática do delito de tráfico de drogas e ensejou a prisão em flagrante do agravante.

3. Embora de forma sucinta, restou demonstrada a existência dos requisitos necessários para a decretação das medidas, escorado nos argumentos da representação policial e na requisição do MP/SP.

4. Impende asseverar que não se pode confundir concisão de fundamentos com a sua ausência, capaz de ensejar ofensa ao disposto no art. 93, inciso IX, da Constituição. Vale destacar, ainda, que é pacífico neste Superior Tribunal de Justiça orientação jurisprudencial segunda a qual é válida a utilização da fundamentação per relationem como razões de decidir.

5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 797.460/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 24/5/2023.)

Não há que se falar em nulidade da sentença. As teses da defesa foram satisfatoriamente consideradas. A defesa trouxe argumentação que visava retirar a credibilidade da vítima Alexandre, contudo, o magistrado apresentou suas declarações respaldas pelas declarações de testemunhas relacionadas à investigação realizada. A resposta para a argumentação defensiva é identificada na sentença: a vítima Alexandre teve sua narrativa corroborada e valorizada.

MÉRITO

Subsiste a condenação de Walter Dias de Almeida pela prática do delito de roubo majorado, estando superados os demais enfrentamentos como visto acima. A defesa aponta as declarações de Walter como versão a ser acolhida, destacando a negativa da autoria. Alega que Walter é tão vítima quanto Alexandre. Destaca que ele estava no local do crime, foi rendido pelos criminosos e ficou fortemente abalado como constou de depoimentos (Franklin e Crézio Teodoro). Afirma que só depois de algum tempo, Alexandre começou a supor uma participação de Walter no roubo; que a quebra de sigilo

nada evidenciou, a não ser ligações entre ele e seus irmãos e entre ele e Carlos Alberto que se deslocava em direção à cidade para receber dinheiro de Walter. Sustenta que a palavra de Alexandre, destoante dos testemunhos e em contradição com as provas, não pode sozinha fundamentar a condenação.

Ao contrário do que alega a defesa, a palavra da vítima não sustenta isoladamente a condenação prolatada e não está em dissonância com as demais provas produzidas. Há respaldo e a sentença apontou os elementos de prova.

Narrou a denúncia que na data de 07 de abril de 2005, por volta das 12 horas, na Rua Afrânio Peixoto, nº. 121, Bairro Catalão, em Divinópolis, os denunciados Carlos Alberto, Celso Victória e Walter Dias, com mais três indivíduos não identificados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram aproximadamente R$380.000,00 em cheques diversos, R$600,00 em dinheiro, uma pistola semiautomática calibre 380 com 2 carregadores, um revólver calibre 32, dois telefones celulares, aparelho de toca CD da marca Pionner, cartões de crédito, talões de cheques e documentos pessoais pertencentes à vítima Alexandre Daldegan Custódio, além de talões de cheques de Nélson Custódio e Cláudio Duarte Pereira.

Não há questionamento sobre a materialidade que, efetivamente, restou incontroversa.

O julgador a quo, analisando com precisão a prova dos autos, concluiu que apenas em relação a Walter restou devidamente demonstrada a autoria.

A vítima Alexandre, às fls. 1108/1113, descreveu detalhadamente como se deram os fatos:

"...que emprestava dinheiro a Walter, no início ele alegou que estava em dificuldades numa fábrica de ternos que ele tinha; que há mais de um ano anterior ao assalto, vinha emprestando dinheiro a Walter; (...); que no dia do assalto Walter chegou no escritório de

declarante por volta das dez horas e ficou lá até o momento do assalto; que nesse período em que Walter ficou no escritório ele deu uma saída dizendo que ia no hospital Santa Lúcia visitar um tio dele; que Walter não demorou nem dez minutos e retornou ao escritório; que entre a saída e retorno de Walter do escritório se deu por volta de onze horas; que o declarante viu três assaltantes, foram os que efetivamente entraram no seu escritório; (...); que a fechadura dessa porta do escritório é elétrica e a tranca fica debaixo de sua mesa; que essa porta sempre fica fechada, mesmo quando o declarante está dentro do escritório com alguém; (...); que quando estavam dentro de sua sala o celular de Walter tocou duas vezes e era a cobrar, nessas duas vezes Walter falava "espera um pouco daqui uns minutos vai dar certo"; que ele colocou o celular no bolso mas o aparelho continuou vibrando quando tocava; que Walter pediu que o declarante abrisse a porta da sala para ele ir no banheiro, que de sua mesa destravou a porta e Walter saiu retornando uns minutos depois, foi ele que fechou a porta e o declarante achou que ele tinha travado a porta; (...); que quando Walter encostou a porta o declarante não ouviu o baque do trave, e Walter já entrou conversando sobre a pescaria, não tendo o declarante notado que ele não chegou a travar a porta; que dois minutos depois disso os assaltantes entraram; que nenhum dos assaltantes estava encapuzado; que não conhecia nenhum dos assaltantes mas guardou a fisionomia deles, eram três; que ficou um quarto assaltante no corredor da casa mas não chegou a vê-lo; (...); que todo material roubado estava dentro do cofre e gaveta; que o cofre é visível para quem entra na sala; que todos os três assaltantes estavam armados; que dois assaltantes já chegaram lhe apontando armas e mandando que ficasse quieto; que o cofre estava aberto; que os assaltantes mesmos é que mexeram no cofre e em três gavetas; que essas gavetas eram da mesa onde o declarante guardava cheques e dinheiro; (...); que os assaltantes foram direto para o cofre e nas três gavetas daquela mesa, nas demais gavetas eles não mexeram, só no final quando já não estava procurando mais nada mexeu nelas para revirar tudo e jogar no chão; que pelo que percebeu os assaltantes já sabiam onde procurar o que queriam; que Walter sabia que o declarante só usava aquela mesa para guardar dinheiro e cheques; que Walter sabia que os cheques estavam nas três gavetas e no cofre

há mais dias; (...); que no sábado de manhã novamente ligou para Walter e ele voltou a negar que tivesse recebido a pasta preta do declarante e ainda perguntou o que tinha nela de tão importante, então começou a desconfiar de Walter e falou para ele que não tinha nada de importante na pasta e que ela deve ter sido levada também no assalto; (...); que durante o curso do inquérito do assalto foi procurado por Walter, ele propôs que o declarante esquecesse o inquérito se ele pagasse as dívidas que tinha para com o declarante, Walter fez essa proposta via telefone; que Walter queria que o declarante retirasse a queixa do assalto na depol; que disse a Walter que a representação já tinha sido feita não tinha como retirar; que Walter não justificou o motivo de querer que a queixa do assalto fosse retirada, disse que pagaria suas dívidas para com o declarante e que deixasse o inquérito para lá porque não ia dar em nada; que os dois acusados presentes nesta sala, Celso e Edmar, não parecem com nenhum dos três assaltantes que entraram no seu comércio no dia do fato; que posteriormente ao assalto conversou com Claudinho seu funcionário e este relatou que no dia do assalto Walter insistentemente perguntou a ele se ele iria almoçar, isso umas três vezes e ainda perguntava quando ele iria almoçar dizendo Claudinho que tinha estranhado estas perguntas; (...); que nos últimos sessenta a noventa dias que antecederam ao assalto Walter não estava pagando ao declarante os empréstimos que ele fazia; que depois do assalto, dos cheques que os assaltantes levaram, referente aos cheques de clientes de Walter entregues ao declarante foram depositados um cheque do cunhado dele (Walter dizia que era vendedor dele), um cheque de Juliano Toscano e um outro cheque de Willian de Lima, são os que o declarante recorda agora; que da dívida que Walter tem para com o declarante, tentou vários acordos com ele, mas Walter não cumpriu todos; que Walter ainda deve dinheiro para o declarante em pagamento, de titularidade da esposa dele, isso a uns cinco meses atrás voltou sem fundos; que tem uma nota promissória consigo assinada por Walter, mas não do valor total que este deve ao declarante; que depois do assalto Walter pagou ao declarante pelas dívidas que tem consigo em torno de cinquenta a cinquenta e cinco mil reais; que atualmente Walter ainda deve ao declarante em torno de noventa a cem mil reais, não sabendo dizer agora o valor exato do

débito que Walter tinha consigo na época; (...); que quando pediu que Walter deixasse a pasta e HD na casa de Juliano ele demorou uns cinco minutos para retornar ao escritório dizendo que tinha deixado com Cleber, depois ele gastou uns dois minutos quando voltou dizendo que tinha deixado tudo no porta-malas do carro; que o assalto durou de seis a oito minutos; que não reconhece a pessoa cuja foto consta às fls. 814 dos autos (Carlos Alberto) como sendo um dos três assaltantes que viu; (...); que alguns cheques levados no assalto foram compensados, não sabe aqui relacionar quais; (...); que a maioria dos cheques estava no cofre, nas gavetas onde os assaltantes tiraram as coisas, havia alguns cheques a carteira e documentos do declarante e seu talonário de cheques; (...); que a única relação que ele teve com a empresa Bros Confecções é de cheques que Valter lhe passou em pagamento de empréstimos que fez a ele;(...)".

A sentença, além das declarações de Alexandre, identificou e valorou as declarações da vítima Cláudio Duarte:

A vítima C.D.O., às fls. 1161/1162 confirma as declarações de fls. 713/714. Afirma que no dia dos fatos estava no escritório quando Walter chegou e no momento que saiu para almoçar Walter e Alexandre estavam dentro do escritório reservado e a porta trancada. Diz que Walter lhe perguntou se iria almoçar, tendo respondido que sim, mas não sabia a que horas seria isso. Por fim, afirma que teve um talonário de cheques subtraído na ação.

A prova oral que consta da fundamentação da sentença afasta a alegação defensiva acerca da negativa de autoria:

A testemunha M.D.B., às fls. 1166, confirmou as declarações de fls. 651/652. Informou ser a proprietária do bar situado próximo ao local do assalto, e que no dia dos fatos, estiveram em seu bar cinco rapazes que a princípio disseram que iriam almoçar, tais pessoas chegaram ao bar por volta das 10 horas e saíram por volta das 12 horas e, nesse período, por várias vezes, eles atravessaram a rua e fizeram ligações no telefone celular, e quando os celulares deles tocavam, atravessavam a rua e iam até o outro lado para atender a

ligação.

W.C.S., às fls. 1114/1116, confirmou o conteúdo das comunicações de serviço de fls. 26/30, 119/123, 339/348, 580/585, 640/644 e 761. Informou que nas investigações apurou a participação de Walter no assalto que vitimou Alexandre, pelos elementos colhidos ele foi o mentor da subtração, pois planejou a ação e fez contato com os executores. Esclareceu que inicialmente Walter figurava também como vítima, mas ao perceber a participação dele no fato e cientificá-lo dessa suspeita, Walter se recusou a prestar qualquer outra informação, dizendo que só falaria em juízo. Relata que quando questionado a Walter quanto aos telefonemas no dia do roubo, ele dizia que não se lembrava do conteúdo de suas conversas. Por fim, afirmou que os cheques de William de Lima e Mauro Custódio foram repassados para a vítima pelo acusado Walter, e essas pessoas foram todas vítimas de roubo, furto ou tiveram seus documentos extraviados.

A negativa do ora apelante Walter não subsiste diante do que mais foi produzido e, compreensivelmente, não foi abordado pela defesa nas suas razões recursais.

Aliás, a sentença apresenta claríssima motivação:

"Após depurar toda a prova produzida nos autos, restou demonstrado que o acusado Walter foi o mesmo o mentor da subtração, pois planejou o fato e forneceu as informações aos executores do delito.

Conforme provado nos autos, a maneira como Walter se comportou no escritório da vítima momentos que antecederam ao assalto, sua inquietação, a insistência em saber o horário de almoço do funcionário Cláudio, as várias ligações para pessoas que não quis identificar e ainda a inércia quanto à subtração de seus documentos pessoais, a realização de viagens para outros estados, supostamente, sem sua carteira de habilitação, são elementos seguros que o apontam com um dos autores do roubo.

Além disso, a subtração de cheques, inclusive daqueles emitidos por Walter e que garantiam seu débito para com a vítima, lhe beneficiou, dificultando ou até inviabilizando qualquer ação da vítima para satisfazer seu crédito, já que não dispunha mais do título representativo."

A condenação de WALTER DIAS DE ALMEIDA como incurso nas sanções dos art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal deve ser mantida.

A reprimenda foi aplicada a partir de concreta motivação quanto à culpabilidade, mas há reparo a ser feito, qual seja, as análises desfavoráveis da personalidade, dos motivos e das consequências do crime. Os conteúdos apresentados estão inseridos nos contornos da própria prática criminosa, da persecução criminal, do tipo penal em apreço. Confira-se:

Para Walter Dias, quanto ao roubo, o julgador consignou que "levando-se em conta a culpabilidade do agente, aferida em grau elevado de censurabilidade pelas condições do fato, pois (...) mesmo assim planejou a execução e ainda simulou ser vítima (...) vejo alto grau de reprovabilidade da conduta."

"Os antecedentes são desfavoráveis, pois a CAC de fls. 991/992 consta registro de condenação anterior, a qual será considerada somente nesta fase."

"Personalidade que o desfavorece pois seu modo de agir e de pensar está na contramão dos demais indivíduos. Não assume a responsabilidade de seus atos, tenta confundir a apuração, inventa fatos não comprovados.

Os motivos sem qualidade ética, insuficientes para justificar a ação, as circunstâncias em que se deu a ocorrência são ínsitas ao tipo

penal, mas as consequências transcendem o fato, pois além do prejuízo financeiro abalou o psicológico da vítima.

O comportamento da vítima não contribuiu para o resultado e desfavorece o réu (...)".

Tomado como neutro o comportamento da vítima (ausência de vítima colaboradora), afastadas as conclusões desfavoráveis sobre personalidade, motivos e consequências do crime, fixo a pena base em quatro anos e dois meses de reclusão e doze dias-multa.

Ausentes atenuantes ou agravantes.

Presente as causas especiais de aumento previstas no §2º, incisos I e II, do art. 157, emprego de arma e concurso de agentes, exaspero em 2/5 a pena e concretizo-a em 5 anos e 10 meses de reclusão e 16 dias-multa, à razão mínima.

A exasperação em 2/5 foi devida e concretamente motivada na sentença, atentando o julgador para o correto critério qualitativo e não meramente quantitativo: "Aumentei a pena pelas agravantes, um pouco acima da fração mínima, tendo em vista que houve participação de quatro pessoas na execução do fato (...)".

À luz da revisão da análise de conclusões desfavoráveis relativas ao art. 59, CP, e atento ao quantum estabelecido, fixo o regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, após não conhecer do primeiro recurso,

decreto a extinção da punibilidade relativa ao crime de estelionato para os apelantes Carlos Alberto, Edmar e Felício pela ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, dando por prejudicados os respectivos recursos (terceiro, quarto e quinto recursos). Em relação ao apelante Walter (segundo recurso), decreto a extinção da punibilidade relativa ao crime de estelionato e, quanto ao crime de roubo, após rejeitar as preliminares, mantenho a condenação com a redução das penas e abrandamento do regime prisional, dando parcial provimento ao seu recurso.

Custas ex lege. Comunique-se a decisão.

DES. JÚLIO CÉSAR LORENS (REVISOR) - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. MARCOS PADULA - De acordo com o(a) Relator(a).

SÚMULA: "NÃO CONHECERAM DO PRIMEIRO RECURSO. DERAM POR PREJUDICADOS OS TERCEIRO, QUARTO E QUINTO RECURSOS. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO SEGUNDO RECURSO."